

1500639-80.2022.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARÍLIA VIZZOTTO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... 33, § 4º, e quanto ao regime inicial. 1. Tráfico privilegiado. Cabimento.

Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, já que o réu é primário, não se dedica à atividade criminosa e não integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Atos infracionais que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500639-80.2022.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500639-80.2022.8.26.0063

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE LINO FERNANDES e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARÍLIA VIZZOTTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA e FELIPE LINO FERNANDES, devidamente qualificados na denúncia, dados como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 01 de junho de 2022, às 16h06min, na Rua Alfeu Róvero, n. 280, Vila Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Igarapu do Tietê, Comarca Barra Bonita/SP, os acusados tinham em depósito, para fins de tráfico, 28 porções de crack, com peso total aproximado de 6,34 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares receberam uma informação anônima apontando que dois indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas no local dos fatos. Tal informação detalhava as vestimentas de tais indivíduos naquela oportunidade, bem como indicava que um deles tinha a alcunha de "Gêmeo", enquanto o outro era conhecido como "filho da Dazinha". Ainda de acordo com a informação anônima, tais indivíduos mantinham a droga escondida numa espécie de canteiro existente nas proximidades. Nessas condições, os policiais militares diligenciaram até o local indicado, onde visualizaram o acusado Carlos mexendo em um canteiro, enquanto Felipe aparentava estar esfarelando uma porção de crack. Em revista

peçoal, foi apreendida com Carlos a quantia em dinheiro de R\$ 38,00 e com Felipe o valor em dinheiro de R\$ 20,00. Na sequência, no referido canteiro onde Carlos estava mexendo, foram localizadas e apreendidas as 28 porções de crack supracitadas. Registra-se que as características físicas, vestimentas e alcunhas dos acusados coincidiam com aquelas apontadas na informação anônima recebida anteriormente. Em conversa informal com os policiais, os acusados confirmaram que estavam vendendo drogas naquele local.

Auto de prisão em flagrante delito às fls. 01/02.

Homologada a prisão em flagrante do acusado Carlos, foi convertida em preventiva (fls. 56/58).

Devidamente notificados (fls. 99 e 104), os Réus apresentaram defesa prévia às fls. 100/101 e 106/108.

Recebida a denúncia em 01 de setembro de 2022 (fls. 109/110), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os Réus.

Em alegações finais, o Ministério Público e a defesa se manifestaram oralmente. É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelos termos de depoimento (fls. 03 e 04), pelo termo de declarações (fl. 05), pelo termo de interrogatório (fl. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16), pelas fotografias (fls. 25/26), pelo laudo definitivo de entorpecentes (fls. 87/91), bem como pela prova oral colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha Paulo Cezar Ribeiro, policial militar, em sede policial disse que é policial militar e recebeu delação anônima no sentido de que dois indivíduos, um de blusa azul, calça jeans e chinelo, cujo apelido é Gêmeo, e outro de blusa cinza, calça jeans e tênis, conhecido por ser “filho da Dazinha”, estava vendendo drogas pela Rua Alfeu Rovero, 280, Igarapu do Tietê/SP. Na denúncia chegou a informação de que a droga ficava numa espécie de canteiro, defronte ao numeral 325 do citado logradouro. O depoente se deslocou até lá por volta das 16h06, sendo que ao se aproximar, viu Carlos Henrique Soares da Silva, vulgo “Gêmeo”, mexendo no canteiro que há na calçada do imóvel localizado defronte do número 325. O depoente viu que Felipe Lino Fernandes, filho de “Dazinha”, estava defronte do imóvel de número 280, esfarelado uma possível pedra de crack, que não foi possível resgatar, tendo em vista que esfarelou por completo. Em revista pessoal, foi encontrado com Carlos a quantia de trinta e oito reais em dinheiro em notas diversas. Com Felipe foi encontrado vinte reais em dinheiro. Em ato contínuo o CB PM Neto averiguou a vegetação que Carlos estava “mexendo”, encontrando na mesma vinte e oito pedras de crack, já embaladas para venda. Ambos confessaram ao depoente que estavam vendendo drogas pelo local. Esclarece o depoente que em face de ambos os indivíduos pesa delação anônima por tráfico de drogas. Diante disso, foi dada voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na Delegacia (fl. 03).

Ouvido em juízo, disse que Felipe e Carlos foram abordados várias vezes no local e com eles não achavam drogas. Nesse dia populares informaram onde eles escondiam as drogas, em um canteirinho. Felipe é conhecido como filho da Dazinha e Carlos como gêmeo. O número 280, onde Felipe estava é na frente do 325. Carlos estava mexendo no canteiro. Ambos tinham dinheiro consigo. No canteiro haviam 28 porções de crack. Felipe estava esfarelado uma pedra amarela, que não pode ser apreendida. O delegado não prendeu Felipe e sua mãe ficou brava pois sabe que ele estava envolvido com tráfico, o delegado não quis ouvi-la. Ela teria dito que já estava sendo cobrada em casa por dívidas de drogas.. O Felipe segue correndo de abordagens. Ele sempre nega o tráfico. Eles ficam sentados no 280 e a droga escondida no 325 que é um canteiro, um jardim. Lá no momento admitiram a venda em conjunto.

A testemunha Jose Raymundo de Castro Neto, também policial militar, em sede

policial disse que é policial militar e estava de serviço nesta data juntamente de CB PM Paulo Cezar. Receberam delação no sentido de que dois indivíduos estavam praticando tráfico de drogas pela Rua Alfeu Rovero, 280, Igarapu do Tietê- SP, sendo que as drogas estariam escondidas defronte do imóvel de número 325.

Deslocaram-se até o supracitado local, lá avistando Carlos Henrique Soares da Silva, vulgo "gêmeo", mexendo no canteiro que há na calçada do imóvel localizado defronte do número 325. Próximo do imóvel de numeral 280 estava Felipe Lino Fernandes, o qual foi abordado pelo CB PM Paulo Cezar e foi observado que ele estava esfarelado uma possível pedrinha de crack, a qual não foi possível resgatar. Em revista pessoal, foi encontrado com Carlos a quantia de trinta e oito reais em dinheiro em notas diversas. Com Felipe foi encontrado vinte reais em dinheiro. Em ato contínuo o depoente averiguou a vegetação que Carlos estava "mexendo", encontrando na mesma vinte e oito pedras de crack, já embaladas para venda. Ambos confessaram ao depoente que estavam vendendo drogas pelo local. Esclarece o depoente que em face de ambos os indivíduos pesa delação anônima por tráfico de drogas. Diante disso, foi dada voz de prisão e a ocorrência foi apresentada na Delegacia (fl. 04).

Ouvindo em juízo, disse que ambos são conhecidos da guarnição. Receberam denúncia que ambos estavam traficando na via, que se sentavam no numeral 280 e que no numeral 325 escondiam drogas em um canteiro. Chegando lá, Felipe jogou algo ao solo, foi constatado que era uma pedra amarelada esfarelada que apertava ser crack. Carlos mexia no canteiro e se distanciou. Com Carlos havia 38 reais e com Felipe 20. Felipe falou que ganhou da mãe e Carlos que fazia bicos. No canteiro havia 28 pedras de crack. Ambos confessaram informalmente. A mãe do Felipe foi até a depol e disse que sabia que o filho traficava, pediu a prisão do filho com medo do que pode acontecer com ele junto aos traficantes. Somente foi feito o flagrante de Carlos. A distância entre os números é só uma rua, uns 7 metros.

O Réu Felipe Lino Fernandes, em sede policial declarou que deseja se manifestar apenas em Juízo (fl. 05).

Em seu interrogatório, o Réu esclareceu que a acusação ocorreu como descrito, estava no local e Carlos vinha do banheiro, foram enquadrados pela polícia. Falaram que era uma denúncia. Então ele foi no canteiro e achou 28 porções. Perdeu, estava nessa vida. Não estava esfarelado crack como disseram. As 28 porções eram suas. Conhecia o Carlos da escola, de pequenos. Estava há uns 3 dias vendendo ali. O Carlos não sabe. O Carlos estava saindo de um banheiro de um cortiço ali. Ele não mora ali. Não sabe o que ele fazia ali. Não teve nada nessa vida de drogas, viu que não compensa. Agora sua mãe está de boa consigo, está feliz que está trabalhando. O Réu Carlos Henrique Soares da Silva, em sede policial declarou que não possui advogado. Deseja que sua mãe Joice seja comunicada de sua prisão, mas não possui o telefone dela, de modo que não foi possível contatá-la. Não possui moléstias. Não possui filhos. Não possui queixas em relação à conduta dos policiais militares. Sobre os fatos, informa que deseja permanecer em silêncio e se manifestar apenas em Juízo (fl. 06).

Em seu interrogatório, o Réu negou a acusação, não estava no local, estava na rua de sua casa. Os policiais lhe levaram até a Alfeu Rovero e lá cataram o Felipe Lino. Os policiais lhe colocaram na viatura e depois pegaram Felipe, lhe deixaram umas horas na viatura e depois vieram com as drogas e lhe disseram que estava preso. Conhecia os policiais, desde que saiu da cadeia eles não param de lhe infernizar, sempre era enquadrado e agredido. Não tem nenhuma questão pessoal com eles. Não sabe porque lhe acusariam, acha que por ter passagem. Conhece Felipe da vila, estudaram juntos faz anos. Trabalhou de servente e estava trabalhando na goiaba.

Assim, diante do testemunho dos policiais e dos acusados, não resta dúvida de que a droga apreendida estava com os acusados. Isso porque, não há motivos para supor que os policiais prestaram depoimentos movido de suspeição nem foi aventada qualquer inimizade específica com os acusados, merecendo credibilidade seu depoimento.

O depoimento de policial, como se sabe, goza de presunção de veracidade, sobretudo quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar, justamente como na hipótese vertente. Presume-se a lisura do agente

público, pois investido no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Bis in idem - Inexistência - Regime prisional fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1500492-93.2019.8.26.0569; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021).

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar as alegações dos acusados em detrimento da palavra do servidor público: enquanto o interesse deste é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, os daqueles é eximirem-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Ademais, Felipe confessou que estava no local, em companhia de Carlos e que as drogas foram ali encontradas, sendo sua intenção vendê-la. Ainda que Carlos negue, sua versão sobre estar no local não foi corroborada, o que torna frágil sua defesa. Ademais, os policiais não tinham, segundo o próprio réu, inimizade pessoal consigo. É importante consignar que, além da comprovação da materialidade e da autoria do fato, necessário analisar a responsabilidade criminal dos denunciados, no que se torna imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto pelo art. 52, inciso I, da Lei n. 11.343/03, que enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e; d) conduta e antecedentes do agente, a fim de que possa distinguir a aquisição de droga para uso ou para o tráfico.

No mesmo sentido, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, contempla alguns parâmetros para se determinar se a droga se destinava ao uso pessoal do agente.

Destarte, dispõe o dispositivo em comento que: Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Assim, dúvidas não pairam sobre a apreensão da droga e sua titularidade, sendo certo que, nas circunstâncias em que encontrada a substância ilícita e o local de apreensão, resulta induvidosa a conclusão de que não se destinavam tão somente ao uso pessoal do réu Carlos e Felipe, ainda mais porque estavam acompanhadas de dinheiro (R\$ 58,00) e houve uma denúncia anônima descrevendo as vestimentas dos acusados e suas alcunhas, indicando que ambos estavam praticando o tráfico de drogas e que o ilícito poderia ser encontrado em um canteiro. Assim, a veracidade de tal informação foi constatada pelos policiais militares que encontraram os dois acusados utilizando as vestes descritas, e a droga justamente no local indicado pela denúncia.

Ressalto que, ainda que a quantidade de drogas apreendidas não tenha grande expressão, a intenção de mercancia ficou bem comprovada pelos depoimentos policiais e sob o crivo do contraditório. Além disso, a quantidade de droga apreendida em plena via pública era muito superior ao que seria necessário para eventual consumo pessoal naquela oportunidade. Assim, não há dúvida de que a droga apreendida era destinada ao tráfico.

Cabe frisar que, os policiais militares relataram em juízo de forma uníssona que visualizaram o acusado Carlos mexendo no canteiro em que estavam as drogas,

enquanto o acusado Felipe aparentava estar esfarelando uma porção de crack. Outrossim, em revista pessoal com os acusados foram encontrados dinheiro em notas diversas, cuja origem lícita os acusados não souberam demonstrar. Dessa forma, as circunstâncias do flagrante, a quantidade da droga apreendida, bem como os depoimentos colhidos em juízo indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD). Ressalto que conforme Estudo Técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei n. 11.343/2006, do MPPR disponível em (https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf) a quantidade compatível com o uso diário de crack é de até 15 pedras por dia (entre 11 e 16), sendo que cada pedra varia de 0,1 a 1,5 gramas. Com os acusados foram encontradas 28 pedras de crack; assim, a quantia das drogas e o modo como estavam acondicionadas indicam a mercancia e não o uso.

Dessa forma, impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que os Réus tinham em depósito droga para comercializar a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Comprovado, assim, o agir típico, em sua materialidade e autoria.

O fato imputado aos Réus também é antijurídico, vez que não restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas previstas no art. 23, CP. Eles também são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputável), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes eram exigidas condutas diversas das que exerceram. Presente, assim, a sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é medida que se impõe.

Inexistem qualificadoras ou privilégios a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de aumento de pena e quanto ao Réu Carlos é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

Na espécie, pelo exame da folha de antecedentes (fls. 48/49), verifica-se que o Réu Carlos não ostenta bons antecedentes, eis que já foi condenado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, não demonstrados bons antecedentes, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido, o seguinte precedente:

"Apelação - Defesa - Tráfico de Drogas - Condenação - Prova - Suficiência - Réu preso em flagrante - Materialidade e autoria comprovadas - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Desclassificação - Artigo 28 da Lei Antidrogas - Impossibilidade - Versão de porte para consumo próprio que se mostrou inverossímil - Apreensão de 12 invólucros contendo maconha (11,6 gramas), 09 invólucros contendo cocaína (9,8 gramas), além da quantia de R\$ 175,00 - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Condenação mantida - Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal -- Compensação da circunstância agravante da reincidência com a circunstância atenuante da menoridade relativa - Causa de Diminuição - Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Inaplicabilidade por ausência de requisito legal - Redução que se deve voltar às hipóteses de agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas - Regime fechado que se impõe" (TJSP, Apelação nº 0069766-73.2012.8.26.0050, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 4ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 04/02/2015 - destaques acrescentados).

Já quanto ao acusado Felipe, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Na espécie, o Réu é primário e de bons antecedentes, uma vez que, com exceção deste processo, não teve nenhuma condenação transitada em julgado contra si (fls. 46/47).

Considerando a menoridade relativa e a quantidade de drogas apreendidas, bem assim que não há indicação de que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, entendo que é cabível a redução do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Esclareço que suas passagens infracionais (fls. 47) não podem afastar a causa de diminuição de pena, a um, porque não se referem a crimes propriamente ditos, a dois, por não revelarem dedicação atual criminosa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33, § 4º, da Lei 13.343/06. Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público quanto à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, e quanto ao regime inicial. 1. Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado, já que o réu é primário, não se dedica à atividade criminosa e não integra qualquer organização ou associação para o tráfico. Atos infracionais que não caracterizam reincidência e não podem ser valorados negativamente a título de antecedentes. Precedentes do STF e do STJ. Quantidade da droga apreendida, ademais, que não é alta a justificar a diminuição do quantum de redução da pena. 2. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15048245820198260196 SP 1504824-58.2019.8.26.0196, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 28/05/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Destarte, quanto ao réu Felipe, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, caput e §4º, da LD.

Passo à dosimetria da pena.

Da dosimetria do Réu Carlos Henrique Soares da Silva

O réu é reincidente (fls. 48/49). A quantidade de drogas, embora razoável a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie, a quantidade em gramas líquidas, não é expressiva. Assim, considero que, para agravar a pena com base no art. 42, LD, tanto a quantidade (que no caso não é expressiva), quanto a natureza da droga, devem ser sopesadas em conjunto, nesse sentido:

Básicas do tráfico elevadas apenas pela espécie da droga, apesar de pequena a quantidade e, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, necessário considerar ambos os fatores de forma cumulada -TJSP; Apelação Criminal 0000567-24.2018.8.26.0544; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, de modo que lhe aplico as penas de (05) cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Presente a circunstância agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu foi condenado por sentença transitada em julgado, cuja pena foi cumprida há menos de cinco anos dos fatos narrados na denúncia (autos nº 1500424-

85.2021.8.26.0598 - fls. 48/49). Por outro lado, verifica-se a atenuante da menoridade relativa, (art. 65, I, do CP), já que o acusado contava com 19 anos de idade na data dos fatos. Assim, concorrente a reincidência e a menoridade relativa - devem ser compensados, na forma do art. 67, CP. Dessa forma, a pena-base se mantém no patamar acima fixado.

Em não havendo nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena provisória como pena definitiva, de (05) cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para fixação do regime inicial, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente e fixada a pena acima de 04 anos, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento

de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Da dosimetria do Réu Felipe Lino Fernandes

O réu é primário e possui bons antecedentes (fl. 46). A quantidade de drogas, embora razoável a ponto de indicar o tráfico, não fugiu à normalidade da espécie, a quantidade em gramas líquidas, não é expressiva. Assim, considero que, para agravar a pena com base no art. 42, LD, tanto a quantidade (que no caso não é expressiva), quanto a natureza da droga, devem ser sopesadas em conjunto, nesse sentido:

Básicas do tráfico elevadas apenas pela espécie da droga, apesar de pequena a quantidade e, a teor do art. 42 da Lei 11.343/06, necessário considerar ambos os fatores de forma cumulada -TJSP; Apelação Criminal 0000567-24.2018.8.26.0544; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cajamar - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 06/11/2020.

As demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, de modo que lhe aplico as penas de (05) cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Há no caso, a circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), tendo em vista que o acusado era menor de 21 anos da data dos fatos. Ausentes circunstâncias agravantes. Dessa forma, fixo a pena provisória em seu mínimo legal, restando em (05) cinco anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme exposto acima, há a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em seu percentual de 2/3. Dessa forma, a pena definitiva é reduzida a 1 anos e 8 meses e 166 dias-multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90.

Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 CP, e do art. 42, Lei nº 11.343/06, o Réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor do Conselho da Comunidade desta Comarca, e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP - à razão de uma hora por dia de condenação, sem prejuízo à normal jornada de trabalho do Réu.

Incabível, tendo em vista a disposição contida no art. 77, III, CP.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para:

(i) condenar o Réu CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, inicialmente em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pelo mínimo legal, à razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos.

(ii) condenar o Réu FELIPE LINO FERNANDES, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, convertida em penas restritivas de direitos, e 166 dias-multa, à razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao Réu Felipe, desnecessária a sua prisão cautelar do Réu, posto que insuficientes os requisitos para tanto, podendo, assim, recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).

Quanto ao Réu Carlos, considerando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva não se alteraram, bem como a pena em concreto aplicada, não concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º,

CPP).

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Com o trânsito em julgado:

- a) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b) intmem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- c) expeçam-se guias de recolhimento definitivo;
- d) oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD);
- e) como a quantia apreendida está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP);
- f) expeça-se certidão de honorários;
- g) procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça;

Condeno em custas, porém, desde já, concedo assistência judiciária gratuita por serem representados pela defensoria e diante do relatado em seus interrogatórios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumram-se as diligências necessárias e, oportunamente, arquivem-se.

Barra Bonita, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA